

1500266-31.2021.8.26.0630

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: Aristoteles de Alencar Sampaio
Comarca: Sumaré

Foro: Foro de Sumaré

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/02/2022

... ao acusado Gabriel no tocante ao crime de trafico de drogas e posse de arma de fogo de forma ilegal, absolvendo-se os acusados no tocante ao crime patrimonial pela insuficiência probatória.

A materialidade do delito de tráfico foi demonstrada pela apreensão documentada a fls. 10/14, em que se descreve o material apreendido na posse do acusado réu. Por outro lado, o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sumaré

Foro de Sumaré

1ª Vara Criminal

1500266-31.2021.8.26.0630 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500266-31.2021.8.26.0630

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL EDUARDO DA FONSECA MACIEL e outro

Vistos.

GABRIEL EDUARDO DA FONSECA MACIEL e MICHAEL FELIPE DOS REIS foram denunciados como incurso nas penas do art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, I, por duas vezes, c/c art. 70, todos do Código Penal, enquanto o primeiro foi denunciado, ainda, como incurso no art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei 10826/03, porque, em 27/03/2021, na Avenida Fuad Assef Maluf, 1496, no Jardim Bela Vista, em Sumaré, teriam subtraído para eles, mediante grave ameaça exercida com armas de fogo em face das vítimas MATEUS DOS SANTOS SOARES e JONAS GABRIEL CHINARELLI, bens móveis pertencentes a estas; e, por fim, o primeiro acusado foi denunciado porque na mesma data teria guardado, para fins de tráfico, substância entorpecente que determina dependência química e física, e também arma de fogo e munições, tudo sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar

Os réus foram citados e apresentaram defesa preliminar, tendo a denúncia sido recebida.

Durante a audiência de instrução foi produzida prova oral, tendo sido os réus interrogados.

As partes apresentaram suas alegações finais, tendo o Ministério Público requerido a condenação do réu Gabriel pelos crimes de trafico de drogas e de posse ilegal de armas, posto entender comprovadas a materialidade delitiva e a autoria, sustentando

a absolvição dos acusados no tocante ao crime patrimonial; a defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição dos réus pela insuficiência probatória e, de forma subsidiária, pela desclassificação do delito para uso de droga e pela concessão dos benefícios legais.

Após, vieram os autos conclusos.

Relatados. D E C I D O:

A ação penal merece prosperar em relação ao acusado Gabriel no tocante ao crime de tráfico de drogas e posse de arma de fogo de forma ilegal, absolvendo-se os acusados no tocante ao crime patrimonial pela insuficiência probatória.

A materialidade do delito de tráfico foi demonstrada pela apreensão documentada a fls. 10/14, em que se descreve o material apreendido na posse do acusado réu. Por outro lado, o exame químico-toxicológico revelou consistir a substância apreendida em entorpecente, concluindo, pois, por sua toxicidade e potencialidade para causar dependência (fls.54/55). E, ainda, o laudo pericial de fls. 356/366 comprovou que as munições apreendidas na casa do acusado Gabriel possuíam potencialidade lesiva, razão pela qual fica afastada a tese defensiva acerca da absolvição do acusado pela ineficácia destes artefatos. Assim, a materialidade delitiva foi comprovada.

Análise a autoria delitiva.

Com efeito, o policial ANDERSON ALVES MARQUES disse em juízo que na data dos fatos estava realizando patrulhamento de rotina, quando foi acionado por duas pessoas, que reportaram terem sido vítima de roubo na avenida Fuad Assef Maluf, tendo seus telefones celulares subtraídos. As vítimas acrescentaram que haviam conseguido localizado o endereço para onde foi levado o telefone celular e mostram aos policiais. Os policiais seguiram ao endereço indicado pelas vítimas, avistaram os réus, que foram abordados. Ao serem questionados, os réus negaram a autoria do crime, mas o padrasto do Gabriel autorizou a entrada na residência, onde os policiais encontram as drogas, as munições e algumas armas de brinquedo. Ao ser novamente questionado, o réu Gabriel confessou a autoria dos crimes de roubo e tráfico de drogas, mas o réu Michael continuou negando a autoria do roubo. No entanto, a vítima, ao ver a fotografia dos réus os reconheceu como sendo autores do roubo. A testemunha acrescentou que durante a abordagem a genitora do Gabriel chegou ao local, comunicou o genitor do Gabriel sobre a prisão deste, o pai de Gabriel compareceu ao local e afirmou que havia emprestado a sua motocicleta ao filho na noite anterior. As vítimas reconheceram as armas encontradas na residência do Gabriel como sendo as utilizadas durante o roubo. O aparelho da vítima foi encontrado por guardas municipais em um terreno situado nas proximidades da residência do réu Gabriel.

No mesmo sentido foram as declarações do policial ROSEVALDO DEZEMBRO.

A vítima MATHEUS DOS SANTOS SOARES disse em juízo que no dia dos fatos estava descendo a rua para ir a casa de uma amiga, quando foi abordado por dois indivíduos, que estavam sobre uma motocicleta, armados, os indivíduos o ameaçaram, anunciaram o roubo e subtraíram o seu telefone celular. A vítima foi à delegacia de polícia, mas não reconheceu os réus como sendo autores do crime.

A vítima JONAS GABRIEL CHINARELLI disse em juízo que estava saindo do seu local de trabalho, juntamente com o primo Matheus, quando foi abordado por dois indivíduos, que estavam sobre uma motocicleta, armados, anunciaram um assalto e subtraíram o telefone celular das vítimas. Os policiais militares conseguiram localizar o seu telefone celular através do telefone celular do seu primo, e conseguiu recuperar o seu aparelho em uma região de mata. A vítima não conseguiu reconhecer os réus como sendo autores do crime, pois ambos estavam de com capacete, apenas com a viseira

aberta.

Neste passo, como já declarou o E. Tribunal de Justiça de São Paulo: "Os funcionários da Polícia merecem, nos seus depoimentos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem em defesa coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador" (RT 616/286), e, ainda, "Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecente "(RT 614/275). Além disso, inexistente qualquer razão comprovada e justificada para retirar a credibilidade destes depoimentos policiais, bem como das vítimas, os quais se mantêm válidos e aptos a sustentarem decreto condenatório.

DEIVID GIOVANI DE AZEVEDO AMORIM disse em juízo que conhece o réu Gabriel há cerca de cinco anos, e sabe que ele trabalha como servente de pedreiro e era usuário de maconha, mas não tomou conhecimento do envolvimento dele com o crime descrito na denúncia. O réu Gabriel possuía uma arma de air soft para o seu entretenimento.

ERIKA BAPTISTA DA FONSECA disse em juízo que é genitora do réu GABRIEL e na ocasião vários policiais estavam em sua casa, remexeram todo o imóvel, apreenderam celulares velhos e algumas armas de brinquedo que o réu utilizava para entretenimento. Os relógios apreendidos foram comprados pelo réu de alguns amigos.

GABRIEL GONÇALVES NASCIMENTO DE ARAÚJO disse em juízo que conhece o réu Gabriel desde 2013, pois ele reside no seu bairro. Sabe que ele era usuário de maconha e que fazia uso do entorpecente regularmente. A testemunha nunca tomou conhecimento de que o réu praticava tráfico.

CLAUDINÉIA APARECIDA DOS REIS disse em juízo que é mãe do réu MICHAEL relatou que seu filho estava cumprindo pena em livramento condicional, e na data dos fatos saiu para trabalhar. Algumas horas depois a testemunha recebeu a notícia de que ele havia sido preso.

O réu GABRIEL EDUARDO DA FONSECA MACIEL negou a autoria dos crimes de tráfico e roubo. Disse que na data dos fatos não saiu da sua residência. Os policiais chegaram em sua residência e adentram o imóvel. O réu conhece réu Michael, pois ambos são amigos. Confessou a propriedade da droga encontrada em sua residência, afirmou que era destinada ao seu uso e estava dividida em cerca de seis pedaços. O réu afirmou, ainda, que quando a sua família se mudou para o imóvel as munições já estavam lá e quanto aos simulacros de arma de fogo encontrados na sua casa, eram utilizados para sua recreação.

O réu MICHAEL FELIPE DOS REIS negou a autoria do crime. Disse que não participou do roubo descrito na denúncia. Na data dos fatos passou na casa do Gabriel para pedir uma bicicleta emprestada, pois precisava trabalhar. Alguns minutos depois chegaram os policiais, encontraram as drogas apreendidas, que eram destinadas ao consumo do Gabriel e o acusaram de ter praticado um crime de roubo.

Com este quadro fático, a absolvição do acusados pelo crime de roubo é de rigor.

De fato, embora existam indícios da prática do roubo pelos acusados, fundado nos elementos extrajudiciais, o fato é que em juízo as vítimas acabaram por não reconhecer os acusados como autores do crime, não tendo sido comprovado que em poder deles tenha sido apreendido os bens subtraídos, pesando contra eles, é verdade, a apreensão dos simulacros que podem ter sido usados no crime, além de estarem no local próximo à indicação do sinal dos aparelhos celulares furtados.

De qualquer forma, o quadro probatório no tocante ao crime de roubo não autoriza a

gravosa condenação criminal, impondo-se, por conseguinte, a absolvição dos acusados neste tocante em prestígio ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade.

Já no tocante aos demais delitos, a autoria foi provada de forma suficiente.

De fato, os policiais foram uníssonos na apreensão da quantidade de droga mencionada na denúncia na casa do acusado, juntamente com as munições e a arma artesanal, fato este, inclusive, que foi admitido em juízo pelo acusado.

Nas circunstâncias dos autos, na qual as vítimas haviam informado aos policiais que a moto usada no crime recém ocorrido estava na casa do acusado, e, ainda, que o sinal do celular subtraído indicava aquela região como o local do armazenamento do bem subtraído, e, ainda, havendo a autorização da família do acusado na entrada dos policiais, mostrou-se legítimo o ingresso no local.

O crime de posse ilegal de armas de fogo, que é de perigo abstrato, foi comprovado pela potencialidade lesiva das munições e pela ausência de autorização administrativa para tal posse, consignando-se que é de conhecimento comum de todos a necessidade dessa autorização. Portanto, por esse delito deve o acusado ser responsabilizado.

Passo a análise das drogas.

Já estabelecido que as drogas estavam na casa do acusado, conforme a prova oral indicou de forma segura, resta a análise de sua destinação.

Tendo em vista a elevada quantidade de droga apreendida, cerca de 500 g de maconha, suficiente para a confecção de centenas de porções de drogas, é forçoso reconhecer que a droga apreendida destinava-se ao tráfico e não ao consumo próprio, pois tal quantidade de droga é incompatível com o mero consumo próprio.

Vale consignar que: "Não se desconhece que os acusados possam ser usuários de substância entorpecente. Todavia, a circunstância deles consumirem droga não significa não pudessem traficar. Aliás, é comum que o traficante também consuma, ou que o consumidor trafique para sustentar o vício" (TJSP - Ap. nº 0004176-56.2012.8.26.0663, rel. Des. José Raul Gavião de Almeida, j. em 05.12.2013).

Caracterizado tais delitos, a condenação do acusado é medida de rigor.

Passo à dosimetria da pena.

A pena-base do crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas será fixada acima do mínimo legal, tendo em vista a especial circunstância de se tratar parte da droga apreendida de maconha, entorpecente este que causa dependência, vulnerando com maior intensidade a saúde pública pelos deletérios efeitos à integridade física dos consumidores da droga, havendo, assim, maior desvalor da conduta do acusado quando comparado, por exemplo, com a conduta relativas a outras drogas, como por exemplo, o cloreto de etila, impondo-se a exasperação da pena. A quantidade de droga suficiente para a intoxicação de centenas de usuários de drogas também justifica a elevação da pena. A jurisprudência corrobora este entendimento: "A natureza e a quantidade da droga apreendida, em atenção ao disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, são circunstâncias que, por si só, justificam o aumento da pena-base acima do mínimo legal" (STJ - HC nº 165.387/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, julgado em 8-2-2011, DJe 21-2-2011). Fixo, em razão destas circunstâncias, a pena-base em 6 anos de reclusão e 500 dias-multa, no piso legal.

O acusado não confessou a prática do tráfico de drogas e assim, não faz jus à atenuante legal.

Sobre o redutor do art. 33, §4o, da Lei de DROGAS, tem-se que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação do índice de redução ou até mesmo impedir a sua aplicação da causa de diminuição de pena (STJ - AgRg no HC 562.200/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020). In casu, ante a quantidade de droga apreendida, reduzo a pena em 1/6 perfazendo a pena final 5 anos de reclusão e 416 dias-multa.

Para o crime do art. 12 da Lei de Armas, fixo a pena-base no mínimo legal, perfazendo esta 1 ano de detenção e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, que torno definitiva.

Porque praticadas com dolos distintos e condutas diversas, vulnerando objetos jurídicos diversos, está configurado o concurso material de delitos, razão pela qual somo as penas, a teor do art. 69 do Código Penal, perfazendo a pena final 5 anos de reclusão, 1 ano de detenção e 426 dias-multa.

O regime de cumprimento de pena do crime apenado com reclusão será o inicial fechado, tendo em vista a quantidade da droga apreendida, e, ainda, a circunstância do crime de tráfico de drogas ser por demais grave, sendo certo que atualmente é o crime que mais vêm gerando violência no país, impondo-se reconhecer a necessidade da fixação do regime de cumprimento de pena mais rigoroso. Consigne-se que: "embora a primariedade e o quantum da pena possam permitir, em tese, a escolha de regime mais brando, não há ilegalidade na fixação de regime mais gravoso quando justificado pela quantidade e natureza do entorpecente apreendido, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 33 do Código Penal" (STJ - HC nº 313.085/SP, rel. Min. Joel Paciornik, j. em 21.6.2016). No tocante ao outro delito, será fixado o regime aberto.

Em atendimento ao art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, consigna-se que o tempo de prisão provisória em nada altera a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, ante a ausência de prova acerca dos requisitos subjetivos para a concessão dos benefícios legais, que deverão ser buscados junto ao juiz das execuções criminais (art. 66, III, b, da Lei de Execuções Penais).

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a denúncia formulada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo para:

a) CONDENAR GABRIEL EDUARDO DA FONSECA MACIEL à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, 1 ano de detenção, em regime aberto, bem como ao pagamento de 426 dias-multa, no mínimo unitário, por infração ao art. 33, §4o, da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei 10826/03, absolvendo-o da acusação remanescente pela insuficiência probatória.

b) ABSOLVER MICHAEL FELIPE DOS REIS da acusação descrita na denúncia, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Não poderá o réu Gabriel recorrer em liberdade porquanto respondeu ao processo no cárcere, subsistindo, ainda, os requisitos ensejadores da prisão decorrente do flagrante a fim de garantir a ordem pública contra novos atentados à saúde pública.

A proibição ao direito de recorrer em liberdade aos réus que respondem presos à instrução vem sufragada pela doutrina como se depreende da lição do jurista Guilherme Nucci: "Réu que aguardou preso a instrução: deve continuar detido, após a prolação da sentença condenatória, mormente se foi aplicado o regime fechado ou o semi-aberto. Se antes do julgamento de mérito, que considerou o acusado culpado, estava cautelarmente recolhido, com mais lógica assim deve permanecer após a condenação."

Por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos não pode ser acolhida, pois, além da quantidade de pena cominada, em se tratando de delito gerador de violência social e familiar, e pelo princípio da suficiência, incide o entendimento jurisprudencial pelo qual: "como se trata de crime de tráfico ilícito de drogas, cuja conduta enseja especial censurabilidade pelos efeitos nefastos na saúde dos usuários e na Saúde Pública de um modo geral, além de servir de elemento propagador e incrementador de toda uma ordem criminosa, que tantos malefícios vêm trazendo à nossa Sociedade, não concedo o regime aberto ou a substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direitos, que não bastariam à reprovação do crime."(TJSP - Apelação nº 0021376-71.2012.8.26.0309 - Jundiaí - Rel. Des. Alex Zilevoski, j. 8.4.13).

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu Gabriel no rol dos culpados. Recomende-se esse acusado no local em que se encontra recolhido.

Condene o réu Gabriel ao pagamento das custas processuais.

Deixo de declarar a perda em favor da União dos tablets e celulares apreendidos nos autos porque não se provou a vinculação deles ao tráfico de drogas.

P.R.I.

Sumare, 09 de fevereiro de 2022.

ARISTÓTELES DE ALENCAR SAMPAIO
Juiz de Direito